

1500791-40.2021.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/08/2022
... em recente julgado:

"PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendido o afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado. Parcial cabimento. (...) Circunstâncias concretas do delito, quantidade da droga apreendida e quantia (em dinheiro) de origem não demonstrada, que apontavam para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500791-40.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500791-40.2021.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238652/2021 - 02º D.P. LORENA, 19993996 - 02º D.P. LORENA, 436/21/212 - 02º D.P. LORENA, 2238652 - 02º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAIO HENRIQUE DA SILVA e outro
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de KAIO HENRIQUE DA SILVA e GUSTAVO LUÍS DE PAULA BATISTA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, conforme exordial acusatória (fls. 129/130).

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (fls. 150, Gustavo; e 153, Kaio), apresentando as defesas preliminares (fls. 180, Kaio; e 184/188, Gustavo). A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 189/191).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e uma informante judicial. Após os réus foram interrogados. Na sequência, as partes realizaram os debates orais, em

audiência (mídia às fls. 267).

O Parquet requereu a integral procedência da ação penal, com a consequente condenação dos acusados.

Por sua vez, a defesa de Gustavo pugnou pela sua absolvição, por insuficiência probatória. No mesmo sentido trilhou a defesa do corréu Kaio. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade narcotraficante encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva; como auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotografias (fls. 39/40), laudo de constatação provisória (fls. 43/45) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 121/123), com resultados positivos para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O mesmo se pode dizer quanto à prova de autoria. Senão vejamos.

De acordo com o policial militar Alessandro Vargas da Silva, durante patrulhamento de rotina, Gustavo foi visto entregando a Kaio uma sacola, arremessada tão logo percebida a presença da viatura policial no local. Já Gustavo tentou fugir, sem sucesso, todavia. De acordo com a testemunha, no interior da sacola foram encontrados os entorpecentes mencionados na denúncia. Na ocasião, Kaio admitiu, informalmente, a propriedade dos narcóticos, enquanto Gustavo declarou que apenas passava pelo local. Questionado, disse que não conhecia os réus até o dia dos fatos, e que a dupla estava parada na esquina, sem outras pessoas próximas.

Seu companheiro de farda, Daniel Vieira da Cruz, fez coro às suas palavras.

A esposa de Gustavo (Naiara Aparecida Batista de Campos), contou que presenciou o momento da abordagem de seu marido, negando que este tenha entregue algo a Kaio.

A testemunha Karoline Martins Espíndola afirmou que passou por Gustavo em via pública pouco antes de sua abordagem, nada vendo em suas mãos. Disse, no entanto, que havia um indivíduo na esquina de bicicleta. Segundo a depoente, Kaio estava longe de Gustavo quando foi abordado, e que caminhava em direção a sua esposa, que vinha ao longe.

Já o corréu Kaio declarou-se inocente. Disse que passava pela rua quando avistou uma sacola plástica com uma nota de cinquenta reais. No momento em que se apossou do objeto os policiais militares o abordaram. Afirmou que assumiu a posse das drogas por ter sido ameaçado pelos agentes da lei. Questionado, disse que não conhece Gustavo, e que não havia ninguém na via pública no momento da abordagem. Indagado, negou que estivesse parado na esquina, afirmando que se dirigia à casa de sua namorada. Quanto a sacola, disse que ao perceber que em seu interior, além do dinheiro (R\$ 50,00), também havia narcóticos, tratou de arremessá-la ao ver os policiais. Contou que os policiais militares lhe falaram para apontar Gustavo como o responsável pelas drogas, porém, preferiu assumir sozinho a propriedade destas. Negou, outrossim, que estivesse de bicicleta.

Durante seu interrogatório, Gustavo igualmente alegou inocência. Contou que dirigia-se à casa de sua avó quando avistou sua esposa vindo na mesma calçada em

sua direção e, do outro lado da rua, um rapaz na esquina. Nesse momento, uma viatura policial chegou ao local. Disse que, nessa hora, ficou nervoso, pois já havia sido preso anteriormente, e começou a andar mais rápido, não observando mais os policiais. Em seguida, um dos agentes o chamou para acompanhar a abordagem de outro indivíduo. Após afirmar aos agentes públicos que já possuía uma passagem criminal, estes resolveram prendê-lo também. Questionado, disse que já conhecia os policiais militares, e que o ato de fiscalização pessoal foi observado por outras pessoas. Negou que conhecesse Kaio. Ao cabo de sua autodefesa, disse que os policiais militares apenas exibiram os entorpecentes em sede policial.

Eis, portanto, as provas orais.

Pois bem. Como se vê, a versão defensiva, escorada unicamente na palavra da mulher do corréu Gustavo, não convence.

Inicialmente, registre-se que os depoimentos dos policiais merecem ampla credibilidade, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, em linha com a jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.P.R.A. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

Frise-se que os policiais militares afirmaram que não conheciam os acusados até o dia dos fatos.

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade ou mesmo amizade; poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juiz na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso dos autos é mais um dentre tantos no qual os réus tentam, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova do que alegam.

Perceba-se que, ao contrário das testemunhas de acusação, as quais reproduziram em juízo aquilo que disseram em solo policial (fls. 15 e 16), o acusado Kaio preferiu o silêncio (fls. 19).

Ora, se por um lado tal postura revela o exercício de um direito constitucional, por outro, causa estranheza que o réu tenha deixado de levar ao conhecimento da autoridade policial desde logo o enredo sustentado em Juízo. Ademais, se realmente fosse verossímil sua versão, os agentes públicos teriam apreendido a nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais), o que não aconteceu, todavia.

Além disso, a tese sustentada por Kaio não se coaduna com o afirmado pelo corréu Gustavo (fls. 20).

Lado outro, nota-se que o depoimento da testemunha Karoline não afasta a credibilidade da versão apresentada pelas testemunhas de acusação, na medida em que esta não presenciou o momento em que Gustavo entregou a droga à Kaio.

Além disso, as declarações dessa testemunha também não estão consoantes com o sustentado por Kaio e Gustavo, já que aquela afirmou que o primeiro estaria de bicicleta na esquina (palco dos fatos), fato desmentido por este, e que o segundo foi preso, de imediato, após finalizada sua abordagem, em linha com a versão de Naiara, mas, contrária à do próprio Gustavo.

Assim, encampar as isoladas e distintas narrativas defensivas, cheia de contradições, significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar a palavra dos policiais envolvidos na presente ocorrência agentes que gozam de ampla credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não terem qualquer interesse em incriminarem inocentes, tal como fundamentado acima.

De mais a mais, os réus não demonstraram estratégia criada para incriminá-los, nem apontaram motivo sério que permitisse tal conclusão, logo, não se desincumbiram do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Por fim, esclareço ser desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia para configuração do crime de tráfico de drogas, bastando para tanto a prática de apenas uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, sendo certo que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como nos presentes autos, à luz da vultuosa quantidade de entorpecentes apreendidos (274 microtubos, do tipo eppendorf), e do modus operandi dos réus.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da

Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, o caso é de condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Passo à calibragem penal.

a) KAIO HENRIQUE DA SILVA:

O réu não possui antecedentes (fls. 211). Todavia, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, sua conduta merece valoração negativa nesta etapa, à luz da quantidade de entorpecentes envolvida. Afinal, considerando o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, tão caro à sociedade, deixar de depreciar quem é surpreendido com 297 pinos plásticos, do tipo eppendorf, contendo “cocaína” (168,51 gramas, peso líquido), significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas envolvendo volumes menores de drogas.

Portanto, à vista de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa de Kaio, com 18 anos à época dos fatos. Contudo, ainda que adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a redução de pena, reconduzo-a novamente ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não ser possível estabelece-la em patamar inferior, aqui tornada definitiva, ausentes outras circunstâncias.

O réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas, a despeito da sua condição de primário e de bons antecedentes, aos olhos da lei.

Primeiro, o acusado não comprovou a realização de ofício legítimo para seu sustento, sequer apresentando qualquer ocupação lícita, ainda que estudantil.

Segundo, enquanto menor, Kaio foi processado seis vezes, cumprindo uma medida socioeducativa em razão da prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 76.

Terceiro, poucos meses após sair da Fundação Casa (autos de execução de medida socioeducativa nº 0000336-73.2021.8.26.0323), em 13/03/2021, Kaio praticou a conduta ora sub judice.

Confira-se entendimento semelhante do nosso E. Tribunal de Justiça, em recente julgado:

“PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendido o afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado. Parcial cabimento. (...) Circunstâncias concretas do delito, quantidade da droga apreendida e quantia (em dinheiro) de origem não demonstrada, que apontavam para a comercialização, dedicada, de drogas. Ressaltando-se que o acusado possui diversos registros por atos infracionais, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas, confirmando-se, diante da avaliação realizada, clara dedicação e habitualidade. Impedimento do benefício. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500098-88.2021.8.26.0578; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data

do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022); e

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – (...) – CONFISSÃO DO APELANTE ESCORARA NOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSAS, REVELADA PELO PASSADO MACULADO POR ATOS INFRACIONAIS, IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – (...) – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 1501997-42.2019.8.26.0530; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020) (Ênfase na reprodução).

Quarto, Kaio não possuía moradia nesta cidade e comarca, conforme suas próprias declarações em sede policial (fls. 19), e o seu passado infracional na cidade de Cruzeiro/SP, a comprovar que estava aqui por conta do tráfico de drogas.

Ou seja, sem prejuízo da quantidade de entorpecentes apreendidos, as circunstâncias acima indicam que o indigitado é pessoa que vem trilhando o caminho do mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'”, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de

origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Afinal, a redutora em comento destina-se apenas aquele que age por um impulso, em situação isolada, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico cuidou somente de um desvio em sua vida, o que não é o caso destes autos.

b) GUSTAVO LUÍS DE PAULA BATISTA:

Inicialmente, verifico que a única condenação definitiva do acusado configura reincidência. Logo, será valorada na próxima etapa. Porém, pelo mesmo motivo citado por ocasião da dosimetria de Kaio, fixo a basilar em 1/6 (um oitavo) acima do piso legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na fase intermediária, como já tangenciado acima, incide ao caso a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 212/214 (processo 1501269-19.2019.8.26.0621, trânsito em julgado em 24/05/2021), pelo mesmo crime destes autos. Contudo, também presente a atenuante da menoridade relativa, o réu possuía 20 anos à época. Logo, compenso integralmente tais circunstâncias.

A propósito:

"Apelação. Tráfico de entorpecente. (...) Condenação mantida. Penas e regime irreprocháveis. (...). Agravante da reincidência específica corretamente compensada com a atenuante da menoridade. Precedentes do STJ. (...) Negado provimento aos apelos". (TJSP; Apelação Criminal 1500843-84.2020.8.26.0196; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2021; Data de Registro: 04/12/2021);

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. (...). 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (STJ; REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema 585); e

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A MENORIDADE E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - É cediço que, interpretando o art. 67 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas quando da aplicação da reprimenda. - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do acusado que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Tal entendimento também se aplica quando o caso envolver a menoridade e reincidência específica, pois, onde se têm os mesmos fatos, deve ser aplicado o mesmo direito. - Na hipótese em análise, reconhecida a menoridade, de rigor a sua compensação integral com a reincidência, mesmo específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade à agravante do art. 61, I, do CP, como a multirreincidência, por exemplo, que implicasse a necessidade de uma maior resposta penal. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir as penas do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação". (STJ; HC n. 390.765/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017.) (Sublinhados meus).

Na última fase, ausente outras causas alteradoras da pena, finalizo-a tal como estabelecida na primeira fase.

Registre-se que o indigitado não faz jus a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei de drogas, vez que ausentes os requisitos autorizadores, por conta do seu passado criminal comprometedor.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

"Apelação - (...) Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa - Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (Ênfase na reprodução).

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, para ambos, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis dos acusados, reforçadas pela reincidência específica de Gustavo, com base no artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras por se mostrarem incompatíveis com a natureza hedionda do crime, ora em voga. Ainda que assim não fosse, o montante de pena aplicado, por si só, as inviabilizaria para os dois.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, em 1/30 (um trinta avos) do

salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

a) condenar KAIIO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, diária mínima; e

b) condenar GUSTAVO LUÍS DE PAULA BATISTA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, diária-mínima.

Nego o apelo em liberdade aos acusados. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam suas prisões preventivas se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Ademais, as penas relativamente altas que lhes foram impostas, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual. Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeçam-se guias de execução provisória.

Custas pelos vencidos, observada a gratuidade de justiça, que ora concedo ao corréu Kaio.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado às fls. 157, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Nota-se que a autoridade policial já se encontra ciente da autorização para destruição das drogas e demais apetrechos apreendidos (fls. 137).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se os complementos das guias de execução; b) Intime-se o acusado Gustavo para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as

cauteladas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA